

1512604-22.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... do indubitável envolvimento do acusado com o tráfico, não se tem notícia de há quanto tempo ele e o corréu atuavam juntos, apenas que CÍCERO sabia que CRISTIANO praticava o tráfico de drogas e aderiu à conduta dele naquela oportunidade, alertando-o sobre a chegada dos investigadores e facilitando sua fuga.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512604-22.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 10 de maio de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512604-22.2021.8.26.0344 - Controle 2021/002334

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÍCERO FIRMINO DOS SANTOS NETO

Vistos.

CÍCERO FIRMINO DOS SANTOS NETO (RG: 29.184.541, filho de Francisco Firmino dos Santos e Eva Fernandes dos Santos) e CRISTIANO DA SILVA NICOLAU foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 8h45, na Rua Salvador Salgueiro, nº 540, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, CRISTIANO trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 24,2g (massa líquida) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica. Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, CÍCERO teria concorrido, mediante auxílio material e moral, para que CRISTIANO praticasse o ilícito acima descrito. Recebida a denúncia (fls. 108/110), o réu CÍCERO foi citado (fls. 131) e apresentou resposta à acusação (fls. 135/146). O corréu CRISTIANO, citado por edital (fls. 243/244), não compareceu nem constituiu advogado, sendo determinado o desmembramento do feito em relação a ele (fls. 268). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, com interrogatório do réu ao final.

Alegações das partes constantes do termo retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente em parte.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29), fotografias (fls. 30/31), laudo de constatação (fls. 33/35), laudo definitivo (fls. 97/100) e pela prova oral colhida.

Os policiais civis Wellington e Renato declararam, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, após informações e investigações indicando a existência de um ponto de venda de drogas localizado na Rua Salvador Salgueiro, altura no número 540, defronte a uma viela conhecida como acesso à "Fazendinha", em companhia de outros policiais dirigiram-se ao referido local. De pronto, visualizaram duas pessoas com sacolas plásticas na mão, momento em que CÍCERO, a fim de alertar sobre a chegada da polícia, proferiu, em alta voz, a expressão "moio, olha o bicho" e os dois primeiros se evadiram em direção a um buracão existente nos fundos da favela, não sendo possível a detenção deles. Todavia, durante a perseguição, um deles dispensou uma sacola de cor azul ao chão, no interior da qual havia uma "muca" em plástico transparente contendo 74 (setenta e quatro) pinos com cocaína, sendo 64 (sessenta e quatro) na cor verde e 10 (dez) escuros. Conseguiram efetuar a prisão de CÍCERO, que, na data, exercia a função de "olheiro" e nada possuía de ilícito consigo. Informalmente, o réu confessou que realmente exercia a atividade de "olheiro" e recebia a importância de R\$100,00 (cem reais) a R\$ 20,00 (cento e vinte reais) por dia para executar a tarefa. Ainda, teria indicado que quem promovia a venda no local e conseguiu fugir era a pessoa de CRISTIANO NICOLAU e um adolescente que reside na região sul, cujo nome e outros dados ele não soube explicar. Em juízo, ratificaram integralmente seus relatos. Ambos acrescentaram que Wellington ficou a cargo de perseguir os dois vendedores que ali estavam, enquanto Renato deveria fazer a segurança e procedeu à abordagem de CÍCERO, destacando que este já foi visto por diversas vezes fazendo essa função de "olheiro do tráfico". Questionadas, ambas as testemunhas afirmaram desconhecer as pessoas indicadas por CÍCERO como aquelas que promoviam a venda na ocasião (CRISTIANO NICOLAU e menor residente na zona sul de Marília), sendo certo que não participaram das diligências para a identificação deles. Renato, ainda, destacou que fazia pouco tempo que havia sido designado para a DISE (setembro de 2021) e já havia visto ao menos duas vezes anteriores aos fatos CÍCERO no local, exercendo a função de "olheiro".

O acusado, por sua vez, na delegacia, afirmou que, de fato, exercia a função de "olheiro" a mando de "Pedrinho" (cujos dados não soube fornecer, informando que se trata de indivíduo de estatura baixa, cor branca, com tatuagens no braço, pernas e outros lugares do corpo, além de possuir uma moto XL 600 de cor preta), auferindo cerca de R\$100,00 (cem reais) a R\$120,00 (cento e vinte reais) por dia. Relatou que quem promovia a venda dos entorpecentes na data dos fatos era CRISTIANO NICOLAU, que reside na casa de "Jhow", na Rua João Batista Rafael, sem número, próximo a Igreja São Francisco. Além dele, outro rapaz começou a praticar a venda naquele dia, sabendo que ele reside na zona sul da Cidade. Declarou que exerce a atividade de olheiro há muito tempo, desde que deixou o sistema prisional, em 10 de agosto de 2018, ao cumprir pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Admitiu que alertou os vendedores de drogas assim que notou a chegada dos policiais (gritando: "moio", "tá sujo", entre outras expressões), indicando que, além dele, outras pessoas costumam exercer a mesma função no local, entre elas Vitória, companheira de CRISTIANO NICOLAU, porém, no dia, ela não estava. Exibidas fotos de CRISTIANO e Vitória, o acusado os reconheceu como sendo as pessoas que mencionou em seu interrogatório. Por fim, disse que os entorpecentes apreendidos estavam com Cristiano Nicolau, que os dispensou durante a fuga. Em seu interrogatório judicial, ratificou parcialmente suas declarações anteriores, afirmando ser usuário de drogas e que exerce a função de "olheiro" para sustentar seu vício, bem como que, na data dos fatos, alertou aos vendedores que a polícia havia chegado (em suas palavras, deu "um salve"). Negou conhecer a pessoa de CRISTIANO NICOLAU. Asseverou que usava cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) pinos de cocaína por dia, porém, depois de preso, não fez mais uso de nenhum entorpecente, mesmo não passando por tratamento

para drogadição.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais, sejam civis ou militares, são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido, por analogia: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017).

E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos investigadores foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu. Não bastasse, houve a confissão integral do crime em juízo.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, concorreu diretamente, mediante auxílio material e moral, para que o corréu trouxesse consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, após informações e investigações indicando a existência de um ponto de venda de drogas localizado na Rua Salvador Salgueiro, altura no número 540, defronte a uma viela conhecida como acesso a "Fazendinha", em companhia de outros policiais dirigiram-se ao referido local. De pronto, visualizaram duas pessoas com sacolas plásticas na mão, momento em que CÍCERO, a fim de alertar sobre a chegada da polícia, proferiu, em alta voz, a expressão "moio, olha o bicho" e os dois primeiros se evadiram em direção a um buracão existente nos fundos da favela, não sendo possível a detenção deles. Todavia, durante a perseguição um deles dispensou uma sacola de cor azul ao chão, no interior da qual havia uma "muca" em plástico transparente contendo 74 (setenta e quatro) pinos com cocaína, sendo 64 (sessenta e quatro) na cor verde e 10 (dez) escuros. Conseguiram efetuar a prisão de CÍCERO, que, na data, exercia a função de "olheiro" e nada possuía de ilícito consigo. Informalmente, confessou que realmente estava exercendo a atividade de "olheiro" e recebia a importância de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia para a referida tarefa. Ainda, teria indicado que quem promovia a venda no local e conseguiu fugir era a pessoa de CRISTIANO NICOLAU e um adolescente que reside na região sul, cujo nome e outros dados ele não soube explicar. Ao ser abordado, o acusado, que já havia sido visto em outras oportunidades pelos investigadores no local exercendo a função de olheiro, admitiu que alertou os vendedores de drogas sobre a chegada dos policiais,

em suas palavras "deu um salve". Não bastasse, a testemunha Wellington, incumbida de deter os traficantes, durante a perseguição, viu o momento em que um deles dispensou uma sacola, a qual foi apreendida, sendo certo que, dentro dela, havia 74 (setenta e quatro) microtubos com cocaína.

Assim, em havendo apreensão de droga que o corréu dispensou (e esse fato é incontroverso), tenho que CÍCERO aderiu à sua conduta de efetivamente praticar o tráfico de drogas, eis que estava próximo ao traficante justamente para auxiliá-lo na venda e facilitar sua fuga, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, que faz menção ao colaborador, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico. Ainda, esclareceu que fazia esse tipo de serviço no local, ganhando R\$100,00 (cem reais) a R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

De se destacar que a versão apresentada pelos investigadores foi confirmada pelo próprio acusado, que admitiu auxiliar traficante, recebendo dinheiro em troca, o qual gastava com entorpecentes, eis que usuário.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes - que é o que o réu diz ser - e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecentes apreendida (24,2g - massa líquida - de cocaína, - tudo dividido em mais de 74 - setenta e quatro - microtubos de droga), o alto poder vulnerante deles, além da forma de embalo e as circunstâncias da prisão, que se deu em local conhecido pela venda de entorpecentes depois dos policiais avistarem o corréu e outro indivíduo não identificado com duas sacolas, os quais correram ao serem alertados por CÍCERO (que gritou "moio", "olha o bicho") para avisar comparsas da chegada dos investigadores, revelam que se trata o réu, de verdadeiro traficante. Não se olvide que tudo foi confirmado em juízo pelo próprio acusado.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante das drogas; acondicionamento típico para venda; local já conhecido como ponto de venda de drogas, além das circunstâncias em que flagrado: próximo aos traficantes de modo a concorrer diretamente para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes (haja vista que auxiliou material e moralmente o corréu e o terceiro não identificado), não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico e a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas. De se

notar que o próprio acusado admitiu que trabalhava na cadeia do tráfico, recebendo cerca de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para alertar sobre a chegada da polícia, assim o fazendo desde que deixou o sistema prisional em 2018, ao cumprir pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Ora, evidente que deve ser afastado o benefício em questão.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, não restaram demonstrados todos os elementos previstos no tipo para sua configuração, motivo pelo qual a absolvição é medida de rigor. Com efeito, a despeito do indubitável envolvimento do acusado com o tráfico, não se tem notícia de há quanto tempo ele e o corréu atuavam juntos, apenas que CÍCERO sabia que CRISTIANO praticava o tráfico de drogas e aderiu à conduta dele naquela oportunidade, alertando-o sobre a chegada dos investigadores e facilitando sua fuga.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante, autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Não bastasse, ostenta maus antecedentes (fls. 44/48). Assim, estabeleço a pena em 6 (seis) anos de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/5 (um quinto).

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea, bem com a agravante da reincidência (fls. 60 – réu estava em cumprimento de pena até 2019), inclusive específica (fls. 48), circunstância preponderante e gravíssima, eis que deixa evidente que o réu optou por trilhar o caminho do crime, apesar das oportunidades que lhe foram concedidas pelo juízo da execução e, por via transversa, pela sociedade. Assim, já com a devida compensação, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando ao réu cumprir 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

A pena pecuniária é fixada em 700 (setecentos) dias-multa, cada qual com valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas impostas.

Primeiro, porque o acusado é reincidente. Depois, de se levar em conta que o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de cumprimento inicial de pena em regime mais brando.

Ademais, de se levar em conta a periculosidade da conduta praticada e a quantidade de pena imposta, na forma do artigo 33 do Código Penal.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do Estabelecimento, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ademais, a imposição do regime inicial de cumprimento de pena se deu em razão da reincidência, o que afasta a imediata aplicação do dispositivo em questão.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar CÍCERO FIRMINO DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da imputação da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de

continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, até porque o acusado é reincidente específico, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Providencie-se o necessário para o cumprimento desta decisão e da pena imposta.

P.I.C.

Marília, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA